



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -

in composizione monocratica, nella persona del

dott. PAOLO D'AVINO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64536 del ruolo generale
per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente

tra

Parte_1 (cod. fisc. *CodiceFiscale_1* e [...]

Pt_2 (cod. fisc. *CodiceFiscale_2*), residenti, entrambi, in
Roma, Via Riccardo Forster n. 84,

elett.nte dom.ti in Roma, Via Castiglione della Pescaia n. 61, presso lo
studio dell'avv.to Mirko Saginario, che li rappresenta e difende per
procure speciali alla lite in calce all'atto di citazione,

e

CP_1 (cod. fisc. *CodiceFiscale_3*), residente in
Roma, Via Francesco Patrizio Da Cherso n. 4,

non costituita,

OGGETTO: rivendica proprietà

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 22.1.2020, il
difensore degli attori ha concluso come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ex art. 140 cod. proc. civ. in data 29.9.2017 *Parte_1* e *Parte_2* coniugi in regime di comunione dei beni e comproprietari *pro indiviso* (in virtù di atto di assegnazione a rogito notaio *Persona_1* di Roma in data 9.12.1983, n. 13028 rep. e n. 4854 racc. – trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Roma 1 il 21.12.1983, ai numeri 87405 reg. gen. e 65817 reg. part. –) dell'unità immobiliare (con annessi cantina al piano interrato, distinta con il numero 1, e posto auto al piano seminterrato distinto con il numero 23) al piano secondo (o primo sopra gli uffici), interno 1, scala 1, dell'edificio in Roma, Via Francesco Patrizio Da Cherso n. 4 (censita in catasto urbano al foglio 882, p.lla 425 *sub.* 10, cat. A\2, cl. 5), assumendo che: - con contratto del 10.10.2005 (regolarmente registrato presso l' *Organizzazione_1* di Roma, il 27.10.2005, alla Serie 3, n. 4785), la avevano concessa in comodato d'uso gratuito al figlio *Controparte_2*; - quest'ultimo vi aveva (senza alcun consenso dei comodanti) ospitato, dapprima, il proprio fratello Francesco e, quindi, anche la convivente *more uxorio* di quest'ultimo, *CP_1*, con il loro figlio *Persona_2* (nato il 14.0.2011); - in seguito alla "separazione" fra i due, avvenuta a fine 2012, la *CP_1* aveva continuato da sola, con il bambino della coppia (affidato congiuntamente a entrambi i genitori, ma «collocato» presso la *Org_2*, ad abitare l'appartamento e il Tribunale, con provvedimento del 27.2/12.3.3015, «inopinatamente» qualificando quest'ultimo «casa familiare», ne aveva disposto la provvisoria assegnazione al suddetto genitore «collocatario» del minore; - è, comunque, sopravvenuto, «un urgente e imprevisto stato di bisogno» (per cui gli attori, avendo

garantito con la propria abitazione principale e corrispondendo, in nome e per conto del figlio CP_2 le rate mensili del mutuo fondiario acceso da quest'ultimo per l'acquisto di un immobile da destinare a sua abitazione, debbono poter attingere provvista dal ricavato della vendita dell'immobile in questione), hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la nominata CP_1, per sentir accertare il loro diritto dominicale comune sullo stesso (e l'inesistenza, invece, di qualsivoglia legittimo titolo dell'occupante a detenerlo per sé e/o altri) e, conseguentemente, condannare la controparte a rilasciarlo immediatamente in favore degli attori.

La convenuta non si è costituita e la causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. di parte attrice, rimasto senza risposta l'interrogatorio formale deferito alla CP_1 e assunte, invece, le deposizioni di due testimoni, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza indicata in epigrafe e viene ora in decisione, alla scadenza dell'unico, assegnato termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda congiunta di rivendica non può trovare accoglimento.

§1. È noto, anzitutto, da un lato, che chi (com'è senza dubbio da ritenere, nella fattispecie) agisce in rivendica ha l'onere della c.d. “*probatio diabolica*” (ovvero di dare la prova della proprietà o risalendo *ininterrottamente* all'acquisto originario “a monte” dei successivi trasferimenti derivativi fino a quello di cui ha beneficiato personalmente *oppure* fornendo la dimostrazione – anche attraverso i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi dei successivi

titolari – del compimento dell’usucapione in proprio favore).

La rivendica, invero, esclude, oltre all’esistenza di *qualsivoglia rapporto diretto*, fosse pure soltanto pregresso e poi cessato (contratto traslativo o costitutivo della detenzione che abbia esaurito la sua funzione ovvero del quale sia stata pronunciata o eccepita la nullità, la rescindibilità o la risolvibilità), con la parte convenuta, anche la stessa possibilità, per quest’ultima, di ripetere comunque, fosse pure solo indirettamente, dal preteso avente titolo un qualche diritto sul bene, del quale egli abbia, di fatto, dismesso la detenzione, lasciandovi, tuttavia, l’attuale occupante, che avrebbe, perciò, potuto opporre al *dominus* o ai *condòmini* o a chi fosse loro nelle more succeduto, per paralizzarne la pretesa “recuperatoria”, la sopravvenuta usucapione per inequivoco mutamento della detenzione in possesso.

Mentre, infatti, «l’azione personale di restituzione è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa in precedenza volontariamente trasmessa dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici – tra i quali la locazione, il comodato e il deposito – che non presuppongono necessariamente nel “*tradens*” la qualità di proprietario», con l’azione di rivendicazione «il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo», sicché il fondamento della domanda «non risiede [più] in *un rapporto obbligatorio personale inter partes*, ma nel *diritto di proprietà tutelato erga omnes*, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la “*probatio diabolica*”» (cfr., fra le altre, Cass. ord, 10 ottobre 2018, n. 25052, e Cass. Sez. Un., 28 marzo 2014, n. 7305).

Orbene, nella fattispecie, gli attori, pur avendo, in qualche modo, documentato, con la produzione dell'atto di assegnazione a rogito notaio *Persona_1* di Roma (in data 9.12.1983, n. 13028 rep. e n. 4854 racc.), che la propria dante causa (*Controparte_3* *[...]* era (anche) l'originaria costruttrice, non hanno, invece, documentato, con la produzione di un certificato delle trascrizioni e iscrizioni dell'ultimo ventennio rilasciato dalla Conservatoria (ovvero di una certificazione notarile sostitutiva) – *ricognitivi dello stato giuridico attuale del bene* attraverso la sua storia ipotecaria e catastale degli ultimi venti anni, con relative informazioni e dettagli circa eventuali passaggi di proprietà e variazioni catastali, nonché l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, domande giudiziali o, comunque, vincoli opponibili a essi rivendicanti –, anche *la loro perdurante titolarità* (sia pure soltanto sotto l'aspetto pubblicitario) *dell'unità immobiliare* (con annessi cantina e posto auto) per la quale è causa.

Nei confronti di soggetti che si assume siano estranei al titolo dominicale (e a differenza, perciò, che «nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa», nella quale l'atto di divisione – inidoneo, «in ragione della sua natura meramente dichiarativa, ... a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi» – assume, invece, «rilevanza probatoria, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione»: così Cass., 10 marzo 2015, n. 4730; Cass. ord., 28 maggio 2020, n. 10067), *il diritto attuale di proprietà*, «al pari degli altri diritti reali, non può – in assenza di

altri e più qualificanti elementi e in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 9096 del 24/08/1991; Sez. 2, sentenza n. 3398 del 05/06/1984)» (così Cass. ord., 6 settembre 2019, n. 22339; vedi, altresì, Cass., 4 marzo 2011, n. 5257), anche perché il legittimo contraddittore processuale del rivendicante, siccome mero detentore/occupante “*di fatto*” della cosa rivendicata (se e in quanto, cioè, non vanta, di regola, alcun autonomo – e confliggente – titolo di diritto reale sulla stessa), non è, quindi, anche un effettivo contendente sul ridetto piano delle risultanze dei pubblici registri immobiliari (e non soltanto – ovviamente – la sua contumacia, ma persino la sua difesa in giudizio può non contribuire affatto a qualificare positivamente la pretesa posizione dominicale avversaria ai fini intrinseci dell’accertamento oggetto della domanda).

§2. Dall’alto lato, si accenna in atto di citazione – e se ne discorre più diffusamente nella memoria di trattazione ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. – alla sopravvenienza di «un urgente e imprevisto stato di bisogno» (per cui essi, avendo garantito con la propria abitazione principale e corrispondendo, in nome e per conto del figlio CP_2 le rate mensili del mutuo fondiario acceso da quest’ultimo per l’acquisto di un immobile da destinare a sua abitazione, debbono poter attingere provvista dal ricavato della vendita dell’immobile in questione).

Tale prospettazione difensiva, tuttavia, che *non ha ricevuto adeguata asseverazione processuale* (nulla essendo stato prodotto riguardo all’allegato bisogno), mentre è *irrilevante rispetto alla*

rivendica (che spetta – se spetta – del tutto indipendentemente dai motivi per il quali il proprietario si determini a esperirla contro l’abusivo detentore), *farebbe presupporre una diversa natura della pretesa di rilascio* (non più petitoria, di sostituzione del proprio legittimo possesso a quello – privo assolutamente di titolo – altrui, bensì personale, di restituzione di un bene per l’*inefficacia* – originaria o sopravvenuta – del titolo giuridico in forza del quale il godimento della cosa è stato, a suo tempo, direttamente concesso o fatto indirettamente ottenere all’attuale detentore – che, perciò e fino a un certo punto, l’ha legittimamente esercitato →) *e le due azioni* (la seconda delle quali, per di più, da trattare con il rito speciale locatizio) *non sono fungibili fra loro* (avendo natura e presupposti diversi e dovendo il Giudice stabilire una volta e per tutte il contenuto sostanziale della pretesa, quale – indipendentemente dal *nomen iuris* adoperato, ma nel rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta – risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni processuali tempestivamente formulate nel corso del giudizio, nonché dal tipo di provvedimento richiesto in concreto).

§2.1. Con riferimento, inoltre, a questa diversa alternativa dell’azione personale di rilascio, gli stessi attori (la parte convenuta essendo contumace) hanno allegato, in particolare, che:

- già nel 2007, l’originario comodatario Controparte_2 «acconsentì ... che, nel compendio immobiliare per cui è causa si trasferisse, quale suo mero ospite, anche il ... fratello» maggiore Francesco

CP_2 ;

- non avendo quest'ultimo e la donna (l'odierna convenuta, per l'appunto) con cui aveva una relazione affettiva e che era in attesa di un figlio, «un'idonea soluzione abitativa nell'immediatezza», i due, *a far tempo dal gennaio 2011*, hanno, perciò – e sia pure di propria esclusiva iniziativa –, intrapreso (in attesa, a loro dire, di «reperire un alloggio maggiormente confacente alle loro esigenze») una convivenza *more uxorio* nell'immobile «già prima di allora occupato e detenuto» da parte del predetto Controparte_4 (figlio anch'egli – si ribadisce – degli odierni attori), nel quale, poi, *la coppia ha, invece, continuato ad abitare «per l'intera durata della convivenza – in costanza della quale è, infine, nato, il 14.10.2011, il minore Persona_2 –»*;
- *la relazione e la convivenza fra i due sono definitivamente cessate il 24.12.2012*, allorché il ridetto Controparte_4 si è allontanato dall'abitazione, «trasferendosi altrove»;
- da allora, «il compendio immobiliare per cui è causa è ... occupato e detenuto» dalla CP_1, la quale, per altro, nell'ambito del contenzioso con l'ex convivente (e padre del minore), è divenuta beneficiaria, *nel marzo del 2015, di un provvedimento di assegnazione dell'immobile*, che sarebbe stato «inopinatamente qualificato» dal Tribunale «come “casa coniugale”» (*rectius* “familiare”).

§2.2. Ora, malgrado gli attori, per vero, ripetutamente ribadiscano di non aver mai dato il loro consenso alla detenzione dell'abitazione da parte dell'altro figlio Francesco, dapprima, e da parte di quest'ultimo e della convivente con il minore, in seguito, ma,

anzi, assumano di aver sempre reclamato da costoro (senza successo) la restituzione del bene (circostanza questa, però, non asseverata processualmente), sia la stessa narrazione (sommariamente riportata) dell'atto di citazione (*con i lunghissimi tempi di protratta permanenza della CP_1 nell'immobile* – dove poi è nato, nell'ottobre del 2014, il figlio minore della coppia –) sia le naturali dinamiche delle relazioni genitori-figli (non essendone stati rappresentati al Tribunale aspetti del tutto peculiari) e la forma libera del contratto di comodato immobiliare d'uso gratuito non consentono affatto di escludere che, nella fattispecie concreta, sia intervenuta la concessione, *per comportamento concludente* (cfr., in motivazione, Cass., 27 dicembre 2016, n. 27044) e con consegna c.d. “simbolica” (la stessa non dovendo «rivestire forme solenni né avvenire materialmente», ben potendo, invece, «anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione» della cosa, ove quest'ultima si trovi già di fatto nel godimento altrui: cfr. Cass. 29 gennaio 2003, n. 1293), di un *nuovo comodato* al figlio *Controparte_4*, finalizzato ad assicurare a quest'ultimo e al minore (pur sempre un nipote diretto degli attori) una residenza familiare, sicuramente temporanea, bensì, nelle intenzioni, ma *senza alcuna espressa apposizione di termine*.

§2.3. D'altro canto, com'è noto, l'utilizzazione della ex “casa familiare” costituisce uno degli aspetti principali (insieme – è ovvio – agli obblighi di concorso nel mantenimento) della regolamentazione della fase patologica del rapporto coniugale o di convivenza, dovendo l'Autorità giudiziaria decidere di essa, alla luce del fondamentale criterio del miglior interesse dei figli minori o, comunque, non autosufficienti della coppia (cfr., *ex multis*, Cass., 22 luglio 2015, n.

15367), di guisa che, in quella sede, il fatto che l'immobile sia di proprietà di uno o dell'altro dei coniugi o di terzi *non ha alcun immediato rilievo ai fini dell'assegnazione*, potendo, semmai, venire in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della consistenza dei rispettivi obblighi economici dei componenti della coppia già coniugata o di fatto.

§2.4. Dal punto di vista interno a quest'ultima, il diritto all'assegnazione del bene «non può venire a esistenza se non si accompagna all'allontanamento dalla casa familiare dell'altro coniuge» (o convivente), dal momento che, «se non c'è l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro coniuge» (o convivente), «non manca solo la possibilità di esercitare un diritto (in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegnazione», sicché la condanna si deve ritenere implicita e, secondo un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 31 gennaio 2012, n. 1367), «l'ordinanza attributiva del diritto a uno dei coniugi di abitare la casa familiare è soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, a esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata) (Cass., 1 settembre 1997, n. 8317)», a seconda dei casi, con procedimento gestito dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (ovvero da quello competente per il merito, se è iniziato il relativo giudizio) oppure dinnanzi al giudice dell'esecuzione.

§2.5. Quanto, invece – più in particolare –, al regime di efficacia *ultra partes* del vincolo di destinazione imposto

nell'interesse della prole, stabiliva, dapprima, l'art. 155-*quater* cod. civ. (introdotto dalla legge n. 54/2006) e stabilisce, ora, l'art. 337-*sexies* cod. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 154/2013 e riproduttivo del contenuto della precedente disposizione abrogata) che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono *trascrivibili e opponibili* a terzi ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.».

Inoltre, già l'art. 4, 2° comma, della citata legge n. 54/2006 e poi l'art. 337-*bis* cod. civ. hanno esteso tale disciplina anche ai casi di «separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, *nonché ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio*», e, stante l'equiparazione, *quoad effectus*, ai provvedimenti giurisdizionali, le norme predette si applicano anche per la modifica delle condizioni previste negli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio innanzi all'Ufficiale di stato civile ovvero assunti in esito a procedura di negoziazione assistita di cui alla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Infine, la l. 20 maggio 2016, n. 76, all'art. 1, commi 42 e 43, ha specificamente disposto: «Salvo quanto previsto dall'articolo 337-*sexies* del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. [...] Il diritto [...] viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di

matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto»; al successivo comma 61, ha disposto, altresì, che, nel caso in cui la casa sia nella disponibilità esclusiva del recedente da un contratto di convivenza, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

§2.6. Ne discende, pertanto, anzitutto, che il provvedimento (*intrinsecamente temporaneo*) di assegnazione *ex art. 337-sexies* cod. civ. che venga trascritto ai sensi dell'art. 2643 cod. civ. sarà *opponibile a ogni successivo acquirente dell'immobile* (fin tanto che, naturalmente, persisteranno le esigenze della prole, alle quali il provvedimento stesso è strettamente legato e al cessare delle quali – debitamente accertato – se ne potrà, invece, ottenere la revoca, con la conseguente, piena affermazione del diritto di proprietà altrui).

D'altro canto, la ricordata previsione dell'art. 337-sexies cod. civ., collegando l'efficacia del vincolo rispetto ai terzi, non più alla disciplina vigente in materia di locazione, di cui all'art. 1599 cod. civ. (che, d'altronde e a differenza dell'assegnazione, non priva l'immobile del suo valore d'uso e ne consente la vendita come bene produttivo di reddito, dal momento che l'ipoteca, *ex art. 2811* cod. civ., si estende anche ai frutti del bene e, dunque, anche ai canoni), ma al principio della priorità della trascrizione, di cui all'art. 2644 cod. civ. (secondo il quale «Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi»), va interpretata nel senso che *il particolare regime di destinazione istituito con il*

provvedimento di assegnazione pronunciato fra gli ex conviventi (a tutela del diritto della prole a conservare l'ambiente abitativo dove si svolgeva la vita comune anteriormente al manifestarsi della crisi) non è incontestabile, ma è destinato a non avere effetto:

- a) da un lato, nei confronti del «creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che, perciò, può far vendere il suo immobile come libero» (cfr. Cass., 20 aprile 2016, n. 7776);
- b) dall'altro, nei confronti del terzo acquirente o avente causa dal convivente proprietario che abbia trascritto il proprio titolo prima dell'assegnazione (*a meno che, per altro, non risultino o l'inserimento, nel titolo medesimo, di una c.d. "clausola di rispetto" della situazione abitativa in essere o la stipulazione di un contratto di comodato* – in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare – *con chi occupi l'abitazione*: cfr. Cass., 10 aprile 2019, n. 9990).

§2.7. Nei suddetti casi, pertanto, come il terzo creditore munito d'idonea prelazione potrà liberamente mettere in esecuzione il relativo titolo nei confronti tanto del proprietario eseguendo quanto del genitore provvisoriamente assegnatario dell'immobile, per ottenere – attraverso l'espropriazione di quest'ultimo – la realizzazione coattiva del proprio credito, così il terzo avente causa del diritto reale di godimento sul bene potrà liberamente pretenderne il rilascio o la cessazione dell'occupazione da parte del detentore (ancorché genitore di minori assegnatario dell'abitazione familiare).

§2.8. Per contro (cfr. Cass., 24 gennaio 2018, n. 1744), poiché

«l'opponibilità opera su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione, costituente il titolo in forza del quale il genitore, che non sia titolare in via esclusiva di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, di regola in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa (...)» , *l'efficacia della pronuncia giudiziale ben «può essere messa in discussione»*, avendo riguardo all'effettivo «interesse alla cui tutela è stata rivolta l'assegnazione (come detto, di regola, quello dei figli), *rispettivamente, tra i coniugi*, nelle forme del procedimenti di revisione (previsti, per i soli casi di sopravvenienze, rispettivamente, dagli artt. 710-711 cod. proc. civ. e dall'art. 9 della l. n. 898 del 1970) *e, da parte del terzo*, “non legittimato ad attivare il procedimento suindicato, ... instaurando ... un ordinario giudizio di cognizione ... di accertamento dell'insussistenza” (originaria o sopravvenuta, com'è a ritenersi, non rilevando per il terzo le sole sopravvenienze) “delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale” (in particolare, “per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi ...”), “al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l'occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito” (... in quanto “il perdurare *sine die* dell'occupazione dell'immobile – perfino quando ne siano venuti meno i presupposti ... – si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del

bene, ai sensi dell'art. 42 Cost. e dell'art. 832 cod. civ.” (v. sempre Cass. n. 15367 del 22/07/2015)».

Il terzo creditore o avente causa del diritto reale di godimento, quindi, che abbia ragione di *reagire all'imposizione del vincolo a lui formalmente opponibile*, dovrà, per recuperare/conseguire il pieno possesso dell'immobile a lui, invece, spettante *secundum ius*, espressamente promuoverne (se del caso – beninteso – congiuntamente all'azione di rilascio) un'*idonea declaratoria giudiziale d'inefficacia* (dovendosi in tal senso rimeditare qualche diverso approdo di legittimità, favorevole, invece, alla possibilità di una domanda e di un pronunciamento soltanto impliciti), dal momento che (in caso, ovviamente, di eseguita trascrizione) occorre procedere, altresì, (non tanto alla cancellazione di quest'ultima, quanto, piuttosto) all'annotazione del (nuovo) provvedimento risolutivo del vincolo a margine della trascrizione di quello (precedente) istitutivo dello stesso.

§2.9. In caso, invece, di omessa trascrizione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa d'abitazione della coppia al convivente affidatario o “collocatario” di figli minori (o convivente con figli maggiorenni, bensì, ma non ancora – senza loro colpa – autosufficienti economicamente), avendo per definizione data certa, è, comunque, opponibile, in caso di omessa trascrizione, al terzo acquirente successivo per nove anni dalla data dell'assegnazione.

§2.10. Infine, nel caso, invece, come quello *de quo*, in cui la coppia (coniugata o semplicemente convivente di fatto) disponesse della casa d'abitazione a (mero) titolo di godimento personale (comodato o locazione) concesso volontariamente dal proprietario a

entrambi o a uno soltanto dei componenti della coppia, *gli effetti*, per il primo (proprietario-concedente), *del successivo provvedimento giudiziale di assegnazione* (con il quale uno dei componenti medesimi viene escluso da quel godimento del bene già in atto da parte di entrambi, che viene, invece, “concentrato” in favore della sola persona dell’assegnatario) *restano sottoposti agli stessi limiti che contrassegnavano la stabilità del diritto personale di godimento* in favore della comunità domestica nella pregressa fase fisiologica della convivenza (cfr. Cass. ord., 10 aprile 2019, n. 9990):

«2.2.1 Costituisce “*jus receptum*” dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento con il quale il Giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale - anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario - non investe, modificandoli, la natura o il contenuto del titolo negoziale che regolava la utilizzazione e il godimento dell’immobile prima del dissolvimento dell’unità del nucleo familiare (Corte Cass. Sez. Un., Sentenza n. 13603 del 21/07/2004), alla stregua del quale, pertanto, continuano a essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo il provvedimento giudiziale soltanto a “concentrare” l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario (nella specie non titolare di diritti reali né di un titolo contrattuale nei confronti del terzo acquirente la proprietà dell’immobile, ma piuttosto titolare di autonoma detenzione qualificata in dipendenza del negozio di tipo familiare fondato sulla convivenza coniugale o anche “*more uxorio*” idoneo *ex se* a produrre obbligazioni nell’ambito del rapporto familiare, tra cui quella di attribuire al coniuge in precedenza non titolare di diritti sull’immobile destinato a casa familiare, di un autonomo titolo di detenzione qualificata non riconducibile alla mera ospitalità: Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8047 del 14/06/2001; Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012; id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017) a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del “*dominus*”.

[...]

2.2.3. Occorre rimarcare che, se il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare non è costitutivo di un nuovo diritto, tuttavia deve ritenersi elemento indispensabile – in quanto presupposto di legittimazione – affinché il coniuge (o l’ex coniuge) assegnatario della casa familiare, che non sia già titolare di diritti reali o personali nei confronti del terzo, possa continuare a godere dell’immobile “*utendo jure*” del titolare-comodatario (o del titolare-conduttore), in quanto componente di quel “nucleo familiare” che deve

considerarsi l'effettivo beneficiario dell'uso dell'immobile. In tal senso il contratto di comodato di "lunga durata", figura nella quale si iscrive la concessione in godimento dell'immobile cui è impressa la destinazione d'uso per le esigenze della famiglia, non può ritenersi scollegato dalle vicende del nucleo familiare – tanto nel momento fisiologico che in quello patologico della convivenza matrimoniale o di fatto, in presenza di minori o di figli non autosufficienti – così come accertate nel provvedimento giudiziale adottato dal Giudice nel procedimento di separazione o di divorzio, atteso che solo in seguito a tale provvedimento risultano verificate le condizioni legali che consentono l'assegnazione della casa familiare, in difetto delle quali cessa il presupposto che legittima l'assegnatario – ... non ... titolare di diritti sull'immobile – a permanere nel godimento del bene.

[...]

Premesso, infatti, che con la concessione di un immobile in comodato le parti ne determinano l'uso (art. 1803 c.c., comma 1) e tenuto, altresì, conto che, accanto al comodato a tempo determinato, [nel quale è stato] espressamente convenuto ... un termine finale (art. 1809 c.c., comma 1), e alla concessione in godimento "senza determinazione di durata", che prevede l'obbligo del comodatario di restituzione del bene "*ad nutum*" (cd. precario: art. 1810 c.c.), deve ravvisarsi anche l'ipotesi di comodato a termine, laddove sia possibile desumere la intenzione delle parti di riferire la cessazione del rapporto in relazione alla specifica destinazione d'uso impressa al bene, [è da] osservarsi che, a tale ultima ipotesi, è stato ricondotto *il contratto stipulato in funzione dell'uso dell'immobile per le esigenze della famiglia del comodatario* – e, dunque, *in funzione anche della soddisfazione degli interessi propri di ciascuno dei componenti il nucleo familiare* –, di talché, *proprio in considerazione della esecuzione e del mantenimento del preesistente rapporto di comodato* – così come originariamente definito nel suo contenuto negoziale –, *che non cessa per il solo fatto dell'allontanamento del coniuge che lo aveva stipulato*, [vi] si innesta la vicenda successiva del provvedimento di assegnazione della casa familiare, che viene soltanto a determinare una novazione dal lato soggettivo del medesimo rapporto, rimanendo, pertanto, ferma la disciplina propria del tipo negoziale che impone al comodante di assicurare il godimento del bene fino a che permanga attuale la esigenza familiare alla quale i contraenti hanno inteso fare riferimento (e dunque fino a che il nucleo non si dissolva per l'acquisto della maggiore età e autonomia economica dei figli, ovvero in conseguenza della revoca del provvedimento di assegnazione: vedi Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15367 del 22/07/2015. Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., comma 1, - introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 55 – "il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio"), fatta salva, comunque, la richiesta di restituzione del bene per l'evenienza di un sopravvenuto urgente e imprevisto bisogno del comodante (art. 1809 c.c., comma 2: cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20892 del 17/10/2016).

5. L'assetto degli interessi in conflitto sopra delineato ha ricevuto piena conferma nell'arresto di questa Corte Cass. Sez. Un., Sentenza n. 20448 del 29/09/2014 che, ribadendo la esclusione della riconducibilità al provvedimento

di assegnazione della casa familiare di un effetto espropriativo larvato del diritto reale limitato o del diritto di proprietà – anteriormente acquistato – del terzo che ha concesso in comodato il bene, ha statuito affermando che “Perché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni”.

5.1 La questione della opponibilità del vincolo di assegnazione della casa familiare al terzo è stata esaminata dalle Sezioni Unite del 2014 in relazione al caso del comodato di immobile concesso per uso “personale” dal genitore-proprietario al figlio e da questi destinato alle esigenze della propria famiglia, e ha evidenziato come: o esiste, al momento della adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, un titolo di godimento dell’immobile, valido ed efficace, attribuito ad almeno uno dei coniugi dal proprietario dell’immobile, e allora il vincolo di destinazione giudiziale sarà opponibile al terzo (nel limite infranovenale o ultranovenale, qualora sia stato trascritto), conformando il suo contenuto al preesistente titolo di godimento; o, invece, tale rapporto, seppure instaurato, al momento della emissione del provvedimento di assegnazione era da ritenere già cessato per scadenza naturale del termine finale o perché era stato esercitato il diritto potestativo di risoluzione del contratto o era stata iniziata analoga azione giudiziale, o ancora era stato esercitato il recesso unilaterale, ovvero ancora a esso rapporto era da considerare estranea la destinazione d’uso dell’immobile alle esigenze della famiglia (come, per esempio, nel caso di comodato dell’immobile per esclusiva frequentazione estiva da parte del solo comodatario), e allora, in tutti questi casi, il sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare non sarà comunque opponibile al proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento).

5.2 Ne segue come corollario che l’accertamento della preesistenza di un titolo di godimento “utile”, implica che grava sul coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenni o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, l’onere di provare, “anche mediante le inferenze probatorie desumibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento” o “che, dopo l’insorgere della nuova situazione familiare, il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all’uso familiare e non solo personale” (Corte Cass. Sez. Un. n. 20448/2014 cit.), postulando tale accertamento “una specifica verifica della comune intenzione delle parti, compiuta attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare” (Corte Cass. Sez. Un. n. 13603/2004 cit.).

[...]

... l'estensione di fatto, da parte del comodatario, del godimento dell'immobile anche ai componenti del proprio nucleo familiare formatosi successivamente nel corso della esecuzione del contratto comporta un'evenienza che, se già prevista e considerata dagli originari contraenti come integrativa del convenuto uso del bene, rende opponibile al comodante il sopravvenuto provvedimento di assegnazione; se, invece, non prevista e pattuita – o addirittura esclusa – dalle parti contrattuali, viene a risolversi in una violazione delle obbligazioni “*ex contractu*”, e non consente di rendere opponibile al comodante il successivo provvedimento di assegnazione, salvo il caso in cui non sia desumibile – in base ad accertamento da condurre alla stregua delle risultanze fattuali – una inequivoca concorde volontà dei contraenti, susseguente alla estensione di fatto del godimento, di modificare l'originaria destinazione dell'uso abitativo dell'immobile, riservata al solo contraente-beneficiario, consentendo, quindi, l'uso del bene in funzione delle esigenze del neocostituito gruppo familiare: in tal caso, rientrandosi nella ipotesi precedente, il sopravvenuto provvedimento di assegnazione del bene sarà opponibile al comodante (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20151 del 18/08/2017)».

Nella fattispecie, pertanto, prospettandosi il provvedimento di assegnazione di cui beneficia la convenuta come a loro inopponibile (indipendentemente dalla sua intrinseca efficacia), gli attori avrebbero dovuto produrre (come si diceva poc'anzi) idonea certificazione delle risultanze dei registri immobiliari, al fine di poter congruamente statuire al riguardo – su una base documentale certa –, *in considerazione delle possibili ricadute sul regime di pubblicità immobiliare*.

§3. Spese processuali irripetibili (stante la contumacia della convenuta “vittoriosa”).

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da *Parte_1* e *Parte_2* con atto di citazione notificato *ex art.* 140 cod. proc. civ. in data 29.9.2017, contro *CP_1*, convenuta non costituita, così decide:

- a) Rigetta la domanda;
- b) Dichiarà irripetibili le spese.

Così deciso in Roma, il giorno 7 aprile 2021.

IL GIUDICE
(DOTT. PAOLO D'AVINO)